

1500563-23.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... em crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se abstêm de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à "lei do silêncio" e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

1ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500563-23.2022.8.26.0559 - lauda

## SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500563-23.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083220/2022 - DEL.POL.MIRASSOL, 23870307 - DEL.POL.MIRASSOL, 1050/22/413 - DEL.POL.MIRASSOL, 2083220 - DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FERNANDO FERREIRA RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Lucas Fernando Ferreira Rodrigues dando-o como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, porque no dia 25 de março de 2022, por volta das 15h45, na Rua Luís Pereira da Silva, n. 4.222, Centro, nesta cidade e Comarca, transportava, para fins de mercancia, quatro porções de maconha, bem como, na Rua Diogo Garcia Sanches, n. 3.871, Beija Flor, nesta cidade e Comarca, mantinha em depósito outras três porções da mesma droga (fls. 126/127).

Por ocasião da defesa preliminar não foram aventadas preliminares nem abordado o mérito (fls. 136/138).

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2022 (fl. 139).

No curso da instrução foram ouvidas três testemunhas e interrogado o acusado, que embora tenha admitido possuir drogas em sua casa, negou que estivesse as portando em via pública e que tenha autorizado os policiais a ingressarem em seu domicílio.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram e, em alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da pretensão punitiva estatal, ao passo que a Defesa roga pelo reconhecimento da ilicitude da revista pessoal sem justa causa e da violação do domicílio, com a consequente absolvição em razão da insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Ressalto que as alegações atinentes à nulidade da colheita da prova em razão da suposta ausência de fundadas razões para a busca pessoal e de fundamento para a violação domiciliar podem ser melhor apreciadas no âmbito meritório, eis que a questão influencia direta e absolutamente o deslinde da demanda.

A pretensão punitiva procede.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelos laudos de constatação preliminar e definitiva de substância entorpecente (fls. 21/24 e 105/107), pelas fotografias dos materiais apreendidos (fls. 25/26), pelo laudo de constatação e extração de dados em aparelho telefônico (fls. 159/164), pelas mídias extraídas do telefone celular apreendido com o acusado (fls. 165/951), pelo relatório de investigação (fls. 952/956) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

Por seu turno, a autoria também é certa e repousa sobre o ora réu.

Com efeito, o policial militar Rafael Amadio Regiani, em Juízo, declarou que realizava atividade preventiva de policiamento no bairro Nova Esperança, que é conhecido pela intensa traficância de drogas, quando avistou uma motocicleta com dois homens e decidiu proceder à abordagem, já que o carona segurava uma sacola contendo matéria esverdeada que aparentava ser maconha. Respondeu que na sacola portada pelo acusado havia uma porção de maconha, além de dinheiro. Disse que o condutor da motocicleta era mototaxista e fazia a corrida a pedido do carona, o qual consentiu que fossem realizadas buscas em seu domicílio, onde foram encontradas outras três porções de maconha, além de uma faca e um prato que aparentemente eram utilizados para o fracionamento da substância entorpecente. Respondeu, também, não lembrar se foi apreendido um aparelho de celular.

Na mesma linha foram as declarações do policial militar Anderson Borges de Paula, o qual explicou que a revista pessoal foi realizada diante do nervosismo apresentado pelo acusado ao vislumbrar a viatura, pois ele tentou esconder uma sacola que portava, alocando-a entre o seu corpo e o corpo do condutor da motocicleta.

Confirmou, ademais, que foram encontrados quatro pedaços de maconha no interior da sacola, além de R\$ 137,00 (cento e trinta e sete reais). Respondeu que o celular foi apreendido em poder do acusado quando da busca pessoal.

A testemunha Ricardo Gonçalves, por sua vez, declarou que é mototaxista e na data dos fatos, por telefone, foi acionado pelo acusado para pegá-lo em frente ao supermercado Pedroso e conduzi-lo até as casinhas, no bairro Nova Esperança. Disse que encontrou o acusado, que segurava uma sacola plástica, e questionou se ele estava levando drogas, obtendo resposta negativa. Respondeu que já no bairro Nova Esperança foram abordados por policiais militares, os quais afirmaram que encontraram drogas no interior da sacola plástica portada pelo acusado. Respondeu que não viu o que havia na sacola portada pelo acusado.

A testemunha Icaro Ramos Ribeiro, arrolada pela Defesa, disse que o acusado era seu funcionário e é responsável pelo sustento dos filhos. Quanto aos fatos, nada presenciou nem sabe a respeito. Confirmou que o acusado era chamado de "Luquinha". Por ocasião de seu interrogatório, o acusado apresentou estratégica versão voltada ao reconhecimento da ilicitude das provas que o incriminam. Sustentou que na data dos fatos foi ao mercado e contratou um mototaxista para levá-lo até a casa de sua avó, no bairro Nova Esperança, onde foi abordado pelos policiais militares. Alegou que não portava drogas e que os policiais, os quais desconhecia, constrangeram-no para que fosse informado seu endereço, onde de fato havia drogas que eram utilizadas para seu consumo pessoal e, eventualmente, para comercialização.

Respondeu que a droga que possuía em sua casa era maconha e que no local não havia nenhum prato ou faca com resquícios de maconha e que seu telefone celular estava no interior de sua casa. Afirmou que chamou o mototaxista em ligação realizada de um orelhão que fica a aproximadamente uma quadra do supermercado Pedroso e que os policiais querem prejudicá-lo por já ter passagens pelo sistema prisional. Respondeu, também, que quando interrogado na delegacia estava acompanhado de um defensor constituído e que disse ser usuário para tentar se livrar da prisão, mesma razão que o levou a admitir que portava drogas na rua quando foi abordado pelos agentes públicos.

Ocorre que a partir da detida análise dos elementos informativos e probatórios carreados nos autos se depreende que a negativa trazida pelo réu se mostra insulada nos autos, pois não é minimamente corroborada por documentos, testemunhas ou qualquer outra notícia formalmente inserida no caderno processual – além do que exige pressupor que as drogas apreendidas foram criminosamente plantadas pelos agentes públicos em seu desfavor, tudo, frise-se, sem qualquer base probatória. No ponto, conquanto não sejam dotados de presunção processual de veracidade nem possuam valor probatório superior às demais provas admitidas no campo do processo penal, os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão não podem ser indistintamente desconsiderados tão somente pela natureza da função que exercem, sobretudo quando coesos e uniformes, como no caso.

Ademais, não se pode olvidar que nas ações penais lastreadas em autos de prisão em flagrante corriqueiramente as únicas testemunhas são exatamente os policiais responsáveis pela prisão, especialmente em crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se abstêm de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à “lei do silêncio” e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, confunde-se com o mérito. Ausência de prova do prejuízo. Absolvição. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos réus. Impossibilidade de desclassificação do crime para o de porte para uso próprio. Penas inalteradas. Artigo 41 da Lei de Drogas. Afastamento. Réu não colaborou com as investigações. Regime prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500606-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020) Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Razoável quantidade de drogas e circunstâncias da prisão – Reprimenda. Redução. Afastamento da circunstância judicial desfavorável. Quantidade de droga que não pode ser considerada expressiva – Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500097-75.2019.8.26.0610; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Morro Agudo - Vara Única; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)

No caso, a Defesa não apresenta qualquer elemento objetivo que possa colocar em dúvida a imparcialidade dos agentes públicos e a veracidade dos seus depoimentos, que, frise-se, são firmes, coesos e uníssonos, além de corroborados e confirmados pelos demais elementos informativos e probatórios disponibilizados nos autos, dentre os quais vale destacar a apreensão de considerável quantidade de substâncias entorpecentes, o testemunho de Ricardo Gonçalves, que presenciou a abordagem do acusado, e as cristalinas conversas voltadas ao comércio de drogas firmadas pelo acusado em aparelho telefônico.

Ademais, no tocante à alegação de contradições nos depoimentos policiais, impõe-se registrar que são reduzidas e não demovem a tese acusatória. Deve se ressaltar que policiais militares que atuam na atividade fim da instituição que integram se submetem à elevadíssima quantidade de ocorrências similares, o que torna absolutamente natural que a memória acerca dos fatos apresente pequenas falhas e

contradições, de forma que a avaliação do valor probante dos depoimentos deve se dar à luz de todo o conjunto probatório. Nesse sentido:

Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de mais de mil porções de maconha, de cocaína, de 'crack' e de "MDMA" em poder do acusado – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Inexistência de elementos a comprometerem os depoimentos dos policiais militares – Pequenas contradições em seus relatos, próprias da prova oral e da quantidade de ocorrências que eles são instados a atender – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo, com fundamento no artigo 42 da Lei Antidrogas – Majoração da pena na segunda etapa em razão da circunstância agravante da reincidência – Inaplicabilidade do redutor especial previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, ante a reincidência do acusado – Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância o seu meio de vida – Regime inicial fechado mantido – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1523400-66.2020.8.26.0228; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021)

Nessa toada, pouco ou nada relevante são as contradições indicadas, porquanto há firmeza e coerência no tocante à abordagem do acusado e à apreensão das drogas, fatos corroborados pelos demais elementos de prova.

Ainda, são gritantes as discrepâncias entre as declarações prestadas pelo acusado em Juízo – com o inequívoco propósito de deturpar a dinâmica fática e alcançar a declaração de nulidade das provas coletadas – e aquelas por ele prestadas em sede policial, na companhia de defensor constituído.

Com efeito, na fase inquisitória o acusado disse ser usuário de maconha e que na data dos fatos foi até a cidade de São José do Rio Preto/SP, onde adquiriu a substância para o seu consumo pessoal. Declarou que só encontrou grandes quantidades à venda e retornou para Mirassol/SP de ônibus, sendo que então foi até o supermercado Pedroso e contratou um mototaxista para levá-lo até a casa de sua avó, no bairro Nova Esperança, onde consumiria a droga. Confirmou que transportava a droga que seria destinada ao seu consumo pessoal e que a faca e o prato apreendidos, com resquícios de drogas, eram de sua propriedade.

Ora, em sede policial – na companhia de um advogado, reitere-se – o acusado apresentou narrativa que se coaduna com as demais provas constantes do processo e com o próprio cenário fático, ao passo que em Juízo apresentou versão um tanto fantasiosa.

De acordo com a sua narrativa em Juízo, ele foi abordado aleatoriamente por policiais desconhecidos, que não encontraram nada de ilícito e ainda assim o constrangeram a informar o endereço, diligenciando no local e encontrando vasto material insito ao tráfico de drogas. Não há explicação da razão pela qual a abordagem repousou exatamente sobre o réu e por qual razão o mototaxista que o acompanhava não sofreu nenhuma consequência, já que – segundo a versão fantasiosa do acusado – nenhum deles portava drogas.

Outra das notáveis falácias do acusado em Juízo é a de que, mesmo sendo proprietário de um aparelho celular – o qual os policiais afirmam ter apreendido quando o abordaram em via pública e que era utilizado rotineiramente para a mercancia de drogas –, o acusado não o portava e chamou um mototaxista a partir de uma ligação de um orelhão, a cobrar.

Ora, é pouco credível que companhias de táxi e de mototáxi recebam ligações a cobrar.

E mais, o acusado disse que fez a chamada de um telefone público situado a uma quadra ou uma quadra e meia do supermercado Pedroso, mas em consulta ao sítio da ANATEL verifica-se que o "orelhão" mais próximo do mencionado supermercado – o qual se situa na Rua Cláudio Gomes, n. 2.555, Santa Casa, Mirassol/SP, entre as Ruas Osvaldo Cruz e Rubens Blundi – fica a pelo menos três quadras e meia de distância (esquina da Rua Antônio Prado com a Avenida Eliezer Magalhães).

Ora, de acordo com a tese de autodefesa, o acusado fez compras no supermercado Pedroso, caminhou aproximadamente quinhentos metros, chamou um mototaxista mediante ligação telefônica a cobrar, pedindo para que este o pegasse no referido supermercado, e então retornou até o estabelecimento, caminhando mais quinhentos metros. Parece que seria muito mais lógico marcar o ponto de embarque, por exemplo, na farmácia Droga Raia, que fica próxima ao “orelhão”, e não em local situado a quinhentos metros.

A narrativa, à toda evidência, é falsa. O acusado portava seu telefone celular, do qual constam valorosos elementos de convencimento, assim como também portava drogas. É isso que os policiais afirmaram de maneira contundente e foi isso que o réu, na companhia de seu defensor, afirmou em sede policial, conforme se constata no trecho oportunamente colacionado (fl. 14):

Esclarece que é usuário de maconha desde os seus 13 (Treze) anos de idade e no ano 2015 foi preso por tráfico de drogas e solto em 2020, e desde então somente é usuário, e que na parte da manhã foi até a cidade de São José do Rio Preto, e procurava por pequena quantidade de maconha para seu uso, porém somente encontrou grande quantidade para comprar, que foi droga posteriormente apreendida. Retornou a este município por transporte coletivo e se deslocou até o supermercado Pedroso onde solicitou um moto taxi que pediu para leva-lo até o bairro Nova Esperança na casa de sua avó, onde iria fazer uso da droga adquirida. Esclarece que está de Regime Aberto e não pode ficar em locais suspeitos motivo que levou a se deslocar a casa de sua avó. Já no bairro Nova Esperança foram abordados pela PM que encontraram a droga em seu poder bem como a quantia que não soube precisar e um aparelho de telefone celular. que os policiais afirmam terem apreendido em poder do agente. Nesse campo, quanto à alegação da Defesa técnica de ilicitude da busca pessoal, razão não lhe assiste. Isso porque o art. 240, §2º, do CPP dispõe que é possível a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculta consigo, dentre outros objetos, drogas. E, no caso, os policiais realizavam patrulhamento em localidade cuja exploração do comércio de drogas é intenso, sendo que um dos agentes avistou a sacola portada pelo acusado com matéria semelhante à maconha, enquanto o outro policial percebeu que o acusado ficou nervoso ao ver a viatura e tentou ocultar a sacola. Tais circunstâncias diferenciam o caso do decidido pelo C. STJ no bojo do REsp 1.961.459/SP, que, aliás, é despido de caráter vinculante.

Nesse sentido é o entendimento do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Abordagem e busca pessoal que estão justificadas, pois de acordo com a lei: fundada suspeita (art. 244 do CPP). Policiais que apontaram de forma segura que, ao visualizar a aproximação da guarnição, o acusado, que se encontrava sentado em uma guia num local conhecido como ponto de tráfico, adotou atitude evasiva, denotadora de fundada suspeita de que tivesse algo ilegal consigo. Desnecessidade, inclusive diante do encontro de drogas com ele e de ser desmentido quanto a estar em outro local, que os policiais expusessem de forma mais elaborada a suspeita que os levava à revista pessoal, que, bom que se diga, independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer momento, mesmo que não se trate de situação de flagrante (não há que se confundir busca pessoal com busca domiciliar). Expertise policial que merece ser prestigiada, assim como são os depoimentos dos agentes da lei. Prova segura da autoria e materialidade. Condenação bem aplicada, merecendo, a r. sentença, ser ratificada na forma do art. 252 do Regimento Interno inclusive no que tange à dosimetria, fixada com critério. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500559-92.2021.8.26.0535; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 09/08/2022)

Da mesma forma, não se sustenta a tese de nulidade das provas coletadas em razão da violação de domicílio do acusado. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão paradigmática, dotada de repercussão geral, fixou parâmetros para que seja considerada válida a entrada em domicílio sem mandado judicial:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.

Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.

Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) - GRIFEI

Destarte, de acordo com a decisão colacionada, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

In casu, a ação policial se adequou ao decidido pelo STF. Isso porque os policiais militares realizaram lícita busca pessoal em via pública que resultou na apreensão de relevante quantidade de maconha, já configurando, dessa forma, o crime de tráfico de drogas. Ademais, já consumado o delito, com a suspeita de que mais entorpecentes estavam no domicílio do réu e com a anuência dele, foram realizadas diligências no local.

Nesse sentido, é o entendimento fixado pelo E. TJSP em recentíssimos julgados: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminares. Crime permanente indicando situação de flagrância apta a autorizar a pronta ação da Polícia, independentemente de mandado, sem se desprezar o fato de o corréu E. haver franqueado o acesso dos policiais ao imóvel. Inteligência dos artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal. Inexistência de ofensa ao princípio da correlação diante do pedido de absolvição formulado pelo Promotor de Justiça em alegações finais. Nulidade inexistente. Matérias rejeitadas. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão parcial do corréu E. Relatos seguros e coesos dos policiais militares, que apreenderam considerável quantidade de droga e apetrechos relacionados ao espúrio comércio. Delito que admite coautoria ou participação. Condenação mantida. Penas-base acima do piso em face de circunstâncias desfavoráveis representadas por antecedentes desabonadores com relação ao corréu R. e acentuada culpabilidade (artigo 42 da Lei de Drogas). Multirreincidência de R., corrigido erro material representado por apontamento de uma das condenações pretéritas atinente à agravante

em pauta. Quadro negativo inconciliável com o privilégio descrito no artigo 33, § 4º, daquela mesma Lei Extravagante, a par de obstaculizar a substituição das corporais por restritivas de direitos providência também colidente com o montante das penas. Regime prisional fechado único adequado ao crime de natureza hedionda, sem se ignorar a existência de circunstâncias adversas e a recidiva de R. igualmente incompatíveis com retiro menos severo. Recursos improvidos, com correção de erro material. (Apelação Criminal nº 1501431-93.2019.8.26.0530, Sertãozinho, rel. Farto Salles, j. 24/06/2021).

APELAÇÃO. Atos infracionais equiparados aos crimes previstos no artigo 33, caput, e 35, c.c. 40, inciso VI, todos da lei n. 11.343/2006. Inexistência de nulidade na ação policial, porque acobertada por hipótese expressamente permitida pelo inciso XI, do artigo 5º, da Constituição Federal. Diante da situação fática-probatória dos autos, verifica-se que não se tratou de mera intuição dos policiais, uma vez que havia elementos que caracterizavam a suspeita de flagrante delito no interior do domicílio. Sentença que, ao contrário do alegado nas razões recursais, apresenta fundamentação idônea, baseada em análise acurada da prova dos autos. Recurso ao qual se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível 1500280-40.2020.8.26.0439; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Pereira Barreto - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

"Habeas corpus" - Tráfico de drogas - Alegação de que as provas foram obtidas ilicitamente, mediante violação de domicílio - Pedido de concessão de ordem para trancar a ação penal e nulificar o feito, com a consequente soltura do paciente - Não acolhimento - Ausência de constrangimento ilegal - Inteligência do art. 5º, XI, da CF, que dispensa consentimento do morador e ordem judicial para o ingresso em domicílio alheio nos casos de "flagrante delito" - Tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" - Crime permanente - Possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP) - Existência de fundadas razões a justificar o ingresso dos policiais na residência do paciente - Precedentes - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057567-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021)

Não se vislumbra, assim, afronta ao disposto no art. 5º, XI, da CF, e aos paradigmas fixados pelos Tribunais Superiores no tocante ao ingresso em domicílio sem mandado.

Assim, é de rigor afastar as alegações de nulidade da prova coletada e de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. O conjunto de elementos informativos e probatórios carreado nos autos - formado substancialmente pelos testemunhos dos policiais militares é válido e hábil a formar o convencimento do julgador.

De toda forma, reitera-se que mesmo que fosse reconhecida a nulidade da diligência realizada no domicílio do acusado, incólume se manteria a acusação e a condenação, porquanto a abordagem em via pública, com a consequente apreensão de drogas, já se fez suficiente à comprovação do delito.

De mais a mais, a quantidade de drogas apreendidas (massa líquida de 440,76g), a forma de armazenamento e acondicionamento das substâncias (porções), bem como os antecedentes do acusado, que possui condenação pretérita por tráfico de drogas, permitem concluir que o material tóxico não era destinado ao consumo pessoal, e sim à comercialização.

Destarte, tanto a existência quanto a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto condenatório, aplicação do princípio do in dubio pro reo ou mesmo desclassificação. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe. Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, conclui-se que, a variedade e quantidade de drogas é circunstância desfavorável, porquanto representam elevadíssimo valor econômico, alto grau de lesividade à saúde pública e se mostram incompatíveis com os volumes

recorrentemente apreendidas nesta Comarca - o que denota maior gravidade do comportamento e justifica o incremento da pena-base. A culpabilidade também é desfavorável, isso porque o agente perpetrava o crime de maneira organizada, com notória e larga reiteração - conforme se extrai das mídias de seu telefone celular -, manutenção de drogas em sua residência e entrega das substâncias a compradores via sistema delivery, tudo durante o cumprimento de pena decorrente de condenação por crime de tráfico de drogas - fatores que denotam a maior reprovabilidade do comportamento e justificam o incremento da reprimenda. O réu ostenta duas condenações transitadas em julgado, motivo pelo qual valoro uma delas (autos n. 0005157-93.2013.8.26.0358) nesta fase e relego a outra para a fase seguinte a fim de evitar o bis in idem (Súmula 241 do STJ). A conduta social e a personalidade são circunstâncias neutras ante a falta de amparo probatório. O motivo do crime é próprio à espécie, assim como as suas circunstâncias e consequências. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Assim, ante a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis e em vista do entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base fica em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes, não havendo se falar em confissão, já que em sede policial a traficância de drogas foi negada e, em Juízo, foi elaborada versão despida de credibilidade e que não foi utilizada para sustentar o édito condenatório (Súmula 545 do STJ). Lado outro, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63 do CP), diante da condenação definitiva imposta nos autos n. 0006375-88.2015.8.26.0358. Dessa forma, agravo a pena intermediária em um sexto e a fixo em 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias multa. Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena. Registre-se que não cabe, no caso, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente, o que, por si só, obsta a aplicação da benesse.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), ante a ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante do teor do art. 33, §§2º, 'b', e 3º, do CP, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Tal cenário não resta alterado, por ora, pela aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Ainda em vista da natureza da infração, da reincidência e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, inviável a sua substituição por restritiva de direitos ou sua suspensão condicional (art. 44, I e II, e 77, I, do CP, e art. 44 da Lei 11.343/06).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado Lucas Fernandes Ferreira Rodrigues como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, à reprimenda de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Lado outro, porquanto permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, mantenho-as. Com efeito, enquanto o *fumus comissi delicti* resta verificado em sede de cognição exauriente, o *periculum in libertatis* é extraído da gravidade em concreto da conduta do réu, que perpetrava a comercialização de elevada quantidade de drogas, e da reincidência múltipla e específica. Logo, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, I, do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado. Recomendem-se à prisão.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos, bem



como o perdimento e destruição dos demais objetos despidos de valor.  
Quanto ao pedido do Ministério Público de extração de cópias e remessa à Polícia Civil para apuração do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, intime-se o órgão ministerial – sem prejuízo do processamento do recurso e andamento regular do feito – para que extraia cópia dos documentos eletrônicos que entender pertinentes e formule à autoridade policial a requisição que julgar cabível, já que melhor pode indicar os documentos importantes e declinar os fatos a serem apurados.  
Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF) expeça-se a guia de execução, assim como o que mais for cabível.  
P. I. C., com observância do art. 392 do CPP.  
Mirassol, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA